

1500742-16.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, com não reconhecimento do tráfico de drogas, eis que se dedicavam a atividades criminosas, e a absolvição no que toca ao delito de associação ao tráfico, por não haver provas suficientes para condenação (fls. 296/300).

A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição de ambos os acusados no tocante ao crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500742-16.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500742-16.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237489/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 19969731 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 999/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2237489 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS, vulgo "Gargamel", RG nº 40716202, nascido aos 26/02/1988, natural de Presidente Prudente/SP, filho de José Carlos dos Santos e de Marli Alexandre da Silva Santos, residente na Rua Luiz Ferreira Lobo, nº 122, Pirapozinho/SP, atualmente preso no CDP Caiuá; e, VANDERLEI FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LIMA, brasileiro, RG nº 48968758, nascido aos 29/10/1993, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Josué Francisco de Lima e de Maria de Lourdes Tereza da Conceição, residente na Rua Dr. Raul Soares de Melo, nº 59, Presidente Bernardes/SP, atualmente preso no CDP Caiuá, como incursos nos tipos penais dos

artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta, dos inclusos autos que, em data, horário e local incertos, mas certo que antes do dia 31 de agosto de 2021, RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS, apelido "Gargamel", qualificado às fls. 09 e VANDERLEI FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LIMA, qualificado às fls. 13, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 31 de agosto de 2021, por volta de 13h30, na Rua Joaquim Custódio Martins, nº135, Vila Marques, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS, apelido "Gargamel", qualificado às fls. 09 e VANDERLEI FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LIMA, guardavam e tinham em depósito, para a entrega ao consumo de terceiros, 15 (quinze) pedras de "crack", com peso líquido de 2,9g e 01 (uma) pedra de "crack", com peso líquido de 9g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de exibição de apreensão (fls. 21/22), de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 07) e laudo pericial (fls. 108/110).

Conforme o apurado, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas e, para tanto, guardavam e tinha em depósito na residência 15 (quinze) pedras de "crack" e 01 (uma) pedra de "crack ainda não fracionada.

No dia da apreensão, policiais civis foram informados por moradores do bairro em que os denunciados residem que eles haviam transformado a residência em uma "biqueira", bem como realizavam o comércio de drogas no imóvel durante o dia, mediante inclusive a troca de drogas por objetos furtados.

Na data dos fatos, policiais civis montaram um ponto de observação próximo à residência dos denunciados e observaram a movimentação de pessoas já conhecidas no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Em seguida, os policiais dirigiram-se à residência e os denunciados se identificaram como os moradores.

Durante revista no imóvel, foram localizadas no quarto de RAFAEL quinze pedras de "crack" fracionadas e prontas para serem comercializadas, acondicionadas dentro de um frasco, bem como uma pedra bruta de "crack" dentro de outro recipiente.

Na residência também foi apreendida uma máquina de cartão de crédito, e com RAFAEL foi localizada a quantia de R\$100,00 (cem reais), de origem lícita não comprovada. Insta salientar que na residência também estava uma terceira pessoa, que alegou estar fazendo a limpeza do quintal em troca da quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) e de um "pedaço" de "crack".

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente a informação de que os denunciados realizavam o tráfico de drogas na residência, a quantidade de droga apreendida, bem como as demais circunstâncias da apreensão, levam a conclusão de que os denunciados estavam associados e que as drogas encontradas destinavam-se efetivamente ao tráfico.

Os réus foram presos em flagrante e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 75/81).

A denúncia foi oferecida em 16/09/2021 (fls. 120/123).

Notificados, os acusados apresentaram defesa prévia por meio de defensor nomeado (fls. 158/161).

A denúncia foi recebida em 25/10/2021, ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento (fls. 164/166).

Na audiência realizada em 26/11/2021 foram ouvidas duas testemunhas em comum, tendo havido insistência na testemunha faltante (fls. 189/190).

Em 30/11/2021 e em 24/02/2021 foi revisada e mantida a prisão preventiva dos réus (fls. 192 e 255).

Juntados documentos pela defesa (fls. 267/270).

Na audiência realizada em 04/03/2022, houve desistência quanto à oitiva da testemunha ausente e, então, foram os réus interrogados. Ao final da solenidade, encerrada a instrução criminal, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva dos acusados, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido (fls. 271/272).

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (fls. 273/275).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, com não reconhecimento do tráfico de drogas, eis que se dedicavam a atividades criminosas, e a absolvição no que toca ao delito de associação ao tráfico, por não haver provas suficientes para condenação (fls. 296/300).

A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição de ambos os acusados no tocante ao crime de associação ao tráfico de drogas e, ainda, pela absolvição de VANDERLEI também com relação ao delito de tráfico de drogas, por entender não haver provas para condenação; em relação ao réu RAFAEL, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 305/309).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, examino diretamente o mérito. Quanto ao tráfico de drogas, a materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial o Auto de Prisão em Flagrante; o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 07); o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21/22); as fotografias da droga apreendida (fls. 37/38); o laudo definitivo da droga (fls. 108/110); e, o laudo de perícia nos aparelhos celulares (fls. 214/240)

Quanto à autoria, necessária análise pormenorizada do conjunto probatório.

Interrogado em Juízo, o acusado RAFAEL confessou o tráfico de drogas, alegando que alugou a residência e estava arrumando, limpando, tendo encontrado Vanderlei no domingo, então o chamou para que o ajudasse a levar uns móveis que estavam na casa de seus pais para a casa alugada, por isso ele estava no local, mas ele não morava ali. Disse que comprou a droga por R\$ 500,00 em Presidente Prudente/SP, com dinheiro que conseguiu fazendo “bicos” como entregador e chapeiro, afirmando que usava de 10 a 8 gramas de crack por dia, sendo que pegava a droga do traficante, usava sua parte e o restante vendia para ter seu lucro e comprar mais droga, bem como para poder pagar o traficante, alegando que o traficante havia lhe mandado mensagem dizendo que queria receber, que se não pagasse iria “arrebentá-lo, iria agredi-lo”, então não viu alternativa; disse que esse traficante já esteve em sua casa e pegou tudo o que tinha de dinheiro, e que ele fornecia drogas dizendo “você vende e me paga”. Contou que em sua casa Vanderlei o viu fumando em seu quarto e pediu para fumar também, de modo que passaram a segunda-feira consumindo a droga. Aduziu que, pelo que sabe, Vanderlei não vendia drogas; ele estava ficando na casa da irmã dele em Presidente Prudente e vinha a Pirapozinho para visitar os filhos, nunca o viu vendendo drogas, tendo ele dito que estava fazendo “bicos” em Presidente Bernardes.

O réu VANDERLEI, por seu turno, negou envolvimento com o tráfico, sustentando que fazia uso de droga quase diariamente e, quanto aos fatos, encontrou Rafael num domingo, tendo ele o chamado para ajudá-lo a retirar uns móveis da casa do pai dele para levar para a casa que ele havia alugado. Negou a informação de que morava com Rafael, reiterando que apenas estava ajudando ele a colocar os móveis para dentro da casa. Disse que haviam feito uso da droga na segunda-feira, mas nunca viu Rafael vendendo droga. Contou que havia movimentação de pessoas na residência de Rafael naquele dia, pois Erick e Diego estavam lá ajudando e também usaram droga junto. Por fim, disse que não tinha conhecimento de que a casa de Rafael funcionava como ponto de venda de drogas.

O Policial Civil Andrews Markus Bratfisch relatou em Juízo que recebeu notícias de que “Gargamel” e Vanderlei estariam traficando drogas em um bairro em Pirapozinho; os vizinhos percebiam movimentação específica de entrada e saída de usuários da casa, e um usuário teria ido à casa trocar um botijão de gás que havia sido furtado de um comércio e traficantes acabaram batendo nesse usuário, o que gerou indignação aos vizinhos, que acabaram denunciando os réus; diante disso, montaram ponto de observação nas proximidades para tentar fazer confirmação das denúncias e viram pessoas entrando e saindo da residência e pelo andar da pessoa e pelo tipo de droga (crack), percebiam que as pessoas que iam até lá eram usuários, sendo que na

residência se deparou com os réus que estavam sentados, e ao serem indagados se havia drogas eles mostraram pedras nos bolsos e mais porções já cortadas. Contou que em conversa informal, as pessoas que estavam do lado de fora disseram que estavam ali para trocar trabalho por droga, contudo, "Gargamel" negou estar vendendo drogas, ele disse que havia comprado droga em Presidente Prudente, tanto a pedra bruta quanto a já fracionada; Vanderlei, por sua vez, comentou que estava na casa havia dois/três dias por ser usuário. Segundo o policial, "Gargamel" disse que meses antes ele possuía um lanche junto com o pai e a máquina de cartão vinha dessa lanchonete, e ao ser questionado sobre o usuário que havia apanhado ele disse que o rapaz realmente havia ido em sua casa, mas não para comprar droga, apenas para usar, como se ali fosse um "fumódromo", e ele não gostou da atitude do rapaz de ter aparecido ali com o botijão. Contou, ainda, que Erick estava nos fundos da casa e disse que havia acabado de sair do trabalho, mas foi confirmado que ele não trabalhava e estava ali usando drogas havia dois dias e ele havia trocado o serviço de retirada de um galinheiro da residência de Rafael por droga. Informou que Vanderlei disse que havia brigado com a irmã dele em Presidente Prudente e "Gargamel" teria admitido ele para morar junto, mas eles não se conheciam antes; e que enquanto "Gargamel" fazia a venda, quem servia a droga era Vanderlei, daí a associação para o tráfico.

Essas declarações foram confirmadas pelo policial Leandro Udenal Guidetti, que narrou que o policial Andrews recebeu algumas denúncias de que em uma residência na Vila Marques alguns indivíduos estariam fazendo tráfico de crack, e além de fazerem a venda da droga eles também recebiam objetos de furto como pagamento pela droga, e nessas denúncias foram citados os nomes "Gargamel" e Vanderlei, além de algumas características físicas; então na data dos fatos Andrews realizou campana no local e confirmou movimentação característica de tráfico e solicitou apoio. Disse que adentraram a residência e dentro de um pote localizaram 15 pedras de crack já preparadas para venda e em um prato uma pedra bruta ainda não fracionada, e próximo à droga havia prato e facas que eram utilizados para cortar a droga. Informou que na casa estava um indivíduo conhecido como Erick que era usuário de drogas e disse que estava ali para prestar uns serviços para o pessoal e o pagamento seria por meio de drogas. Também disse que ambos os réus assumiram que residiam no local. Confirmou que realizaram a campana em virtude de denúncias anteriores de que ali havia tráfico de drogas, inclusive vizinhos informaram que usuários estavam sendo agredidos no local. Esclareceu que a pedra bruta de "crack" foi encontrada dentro do prato com a faca. Também disse que o terreno era dividido em duas residências e verificaram que eles cediam espaço dentro da casa para os usuários consumirem as drogas. Encerrou reafirmando que no dia dos fatos Vanderlei assumiu que morava no local; tanto Rafael quanto Vanderlei disseram que moravam lá.

Acrescente-se o teor das declarações prestadas por Erick Silveira da Silva em solo policial:

"informa que é usuário de crack a mais ou menos 05 (cinco) anos e que nesta data estaria na residência de RAFAEL conhecido como GARGAMEL pois RAFAEL havia pedido para fazer uma limpeza nos fundos do quintal e que em troca lhe daria R\$50,00 (cinquenta reais) para desmontar um galinheiro; que o declarante perguntou se ele tinha entorpecente tipo crack para fornecer e que GARGAMEL disse que depois do trabalho lhe daria um pedaço para usarem; que não tem ciência se GARGAMEL trafica, mas, sabia que ele tinha entorpecente;" (fl. 08)

Não restam dúvidas, portanto, que RAFAEL, efetivamente estava exercendo o tráfico de drogas em sua residência, o que restou comprovado não apenas pela prova testemunhal e pela apreensão da droga no local, mas também pela confissão do acusado e pelas mensagens verificadas em seu aparelho celular.

Com efeito, no celular de RAFAEL foram verificadas mensagens com nítido teor afeto à traficância. Senão vejamos:

Em conversa com o interlocutor identificado apenas como "Brancoo", no dia 30 de agosto de 2021, RAFAEL enviou a seguinte mensagem: "É isso meu quebrada, então vou fazer o seguinte mano, vamo analisar a situação com os mano aqui, é que agora eu tô até demorando pra te atender aí porque eu tô na lojinha, tô metendo marcha numa droga, tá ligado? Aí o negócio é o seguinte, eu só resolvendo essa situação com os

mano, a gente dá um salve em você ou na Jéssica aí, tá ligado? Aí a gente já resolve a quantidade que a gente vai pegar, fechou?". (fl. 229)
É sabido que a expressão "lojinha" refere-se ao comércio de drogas.
Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado RAFAEL estava comercializando drogas em sua residência, e que a droga apreendida nos autos era destinada ao fornecimento a terceiros, incidindo, portanto, nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No que concerne à tipicidade, vale salientar que RAFAEL faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa. In casu, analisando a Folha e a Certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos (fls. 39/40 e 41), verifica-se que o réu é primário, sendo esta sua primeira passagem policial.

Além disso, não há provas de que estivesse se dedicando a atividades criminosas, nem de que integrasse organização criminosa, sendo o tráfico objeto deste processo, ao menos por ora, e à míngua de outros elementos, fato isolado em sua vida.

Todavia, a minorante deve ser aplicada em seu grau mínimo (1/6), diante da natureza altamente nociva da substância entorpecente apreendida.

A propósito do tema, vale salientar que o magistrado possui discricionariedade para o estabelecimento do grau de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA. I - As instâncias ordinárias não deixaram de justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo, pois se reconheceu que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, seriam fundamentos hábeis a aplicar a redução em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/6. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - A pena imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico não desbordou dos lindes da proporcionalidade e razoabilidade. IV - Ordem denegada. (STF - HC: 106611 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-042 DIVULG 02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011)

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu RAFAEL pelo delito de tráfico de drogas, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa.

Porém, o mesmo não ocorre quanto ao réu VANDERLEI, tendo em vista que não ficou devidamente comprovado que VANDERLEI efetivamente estava residindo com Rafael, ainda que temporariamente, e o estivesse auxiliando no tráfico de entorpecentes. O contexto probatório leva a crer que VANDERLEI lá estivesse, em verdade, para consumir droga em troca de serviço.

Dessa forma, as provas produzidas judicialmente não confirmaram os indícios do inquérito policial que levaram ao oferecimento da denúncia, tendo em vista que não há provas suficientes a indicar que esse acusado estava comercializando drogas.

Enfim, o conjunto probatório mostra-se bastante frágil e nebuloso, pairando dúvidas no âmbito desta julgadora, de maneira que, para que seja feita justiça no caso concreto, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Por outro lado, no que toca ao crime de associação ao tráfico de drogas, é imperiosa a absolvição de ambos os acusados.

O mero concurso de pessoas (CP, art. 29) para a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 não induz necessariamente à existência de uma associação para tanto. A configuração do delito do art. 35 da mesma Lei exige a união estável e permanente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Associação para o tráfico - Autoria e materialidade delitiva comprovadas apenas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime prisional fixados com critério em relação a este delito - Associação para o tráfico não configurada - Absolvição que se faz necessária - Ausência de comprovação de que o apelante tenha efetivamente praticado quaisquer atos que indicassem a sua associação, de forma estável e permanente, para a prática da mercancia nefanda - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15017550720208260544 SP 1501755-07.2020.8.26.0544, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2021)

No caso em apreço tanto não há provas do envolvimento do codenunciado VANDERLEI na traficância praticada por RAFAEL, quanto menos de uma união estável e permanente entre eles.

Passo à dosimetria da pena de RAFAEL, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu é primário. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, embora a natureza da droga seja fator autorizador do aumento da pena-base, já será utilizada para determinação do quantum de redução da pena em decorrência da aplicação da minitorante do tráfico privilegiado, assim, para que não haja bis in idem, deixo de considerá-la neste momento. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem aplicadas; em contrapartida, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal). Contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que nesta fase é vedada a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ, de modo

que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento de pena; por outro lado, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assim, nos termos da fundamentação, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos poucos recursos financeiros do acusado (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

In casu, o réu está preso desde 31/08/2021, portanto, há 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, de modo que, detraído tal período da pena aplicada, tem-se pena remanescente inferior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a fixação do REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), observadas as seguintes condições (art. 115 da LEP): a) recolhimento em casa de albergado ou, não havendo, recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h00 às 06h00) e nos dias de folga (sábados, domingos e feriados); b) proibição de se ausentar da Comarca de sua residência por prazo superior a 07 dias, sem autorização judicial; c) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; d) proibição de frequentar bares e outros estabelecimentos similares em que possa ocorrer a distribuição de substâncias entorpecentes; e, e) realizar tratamento toxicológico junto ao CAPS AD do município de sua residência.

Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o "sursis", uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: a) CONDENAR o réu RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS, vulgo "Gargamel", RG nº 40716202, nascido aos 26/02/1988, natural de Presidente Prudente/SP, filho de José Carlos dos Santos e de Marli Alexandre da Silva Santos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos, e ABSOLVÊ-LO quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, b) ABSOLVER o réu VANDERLEI FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LIMA, RG nº 48968758, nascido aos 29/10/1993, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Josué Francisco de Lima e de Maria de Lourdes Tereza da Conceição, quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas que lhe são imputados neste feito (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Como decorrência lógica da absolvição, quanto ao acusado VANDERLEI, e da fixação do regime aberto, em relação ao réu RAFAEL, revogo a prisão preventiva, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Quando da prisão dos réus, além das drogas, foram apreendidos R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro; um aparelho Samsung Galaxy J7 Prime, cor preta e um aparelho celular cor salmão metálico, com tela danificada (fls. 21/22).

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer

bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que os sentenciados não se desincumbiram do seu ônus, decreto o perdimento do aparelho celular pertencente ao réu RAFAEL e da importância em dinheiro, a ser revertida ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das amostras da droga apreendida, bem mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Quanto ao aparelho celular pertencente ao réu VANDERLEI, determino seja a ele restituído, mediante termo nos autos.

Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condeno o réu RAFAEL, também, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal; contudo, por estar assistido por defensor nomeado, concedo os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Arbitro honorários ao defensor nomeado em 100% do valor previsto na tabela do Convênio OAB/DPE. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime aberto e guia de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) proceda-se à liquidação da pena de multa e, a seguir, intime-se o réu para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá ser o réu advertido de que, exceto em caso de absoluta impossibilidade econômica, que deve ser devidamente comprovada, o não pagamento da pena de multa impede a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 3.150/DF, e encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1850903-SP, julgado em 28/04/2020 e divulgado no Informativo de Jurisprudência nº 671; e, e) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA